

予備独自問題 H29-17

(配点: 2)

月 日

月 日

身体検査に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 捜査機関から鑑定の囑託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき、身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。

イ. 捜査機関が身体の拘束を受けている被疑者の顔写真を撮影するには、身体検査令状による必要はない。

ウ. 捜査機関が女子の身体を検査する場合、身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り、これらの者を立ち会わせる必要はない。

エ. 捜査機関が人の着用している下着の中を搜索して物を差し押さえるためには、搜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。

オ. 捜査機関が人の身体から直接強制として尿を採取するには身体検査令状による必要がある。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

No101	身体検査	正答率
予備H29-17	正解 3	62%

ア 誤っている

225条4項・168条6項、139条、172条。捜査機関は犯罪の捜査をするについて必要があるときは、鑑定を嘱託することができる（223条1項）。そして、鑑定の嘱託を受けた鑑定受託者は、裁判所による許可状の発付を受けて、168条1項に規定する「身体を検査」することができる（225条1項、3項）。もっとも、当該許可について定める225条4項は168条6項を準用しているところ、同条項は身体検査の直接強制を認める139条の準用をしていない。また、鑑定人の実施する身体検査については、裁判官による直接強制の途があるが（172条）、鑑定受託者の実施する身体検査には、172条の準用もない（225条4項には172条を準用する定めがない）。よって、法文上、鑑定受託者の実施する身体検査を拒んだ者に対する直接強制の根拠条文はないため、鑑定受託者は、鑑定処分許可状に基づき、直接強制として身体検査を行うことができない。

イ 正しい

218条3項。身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、218条1項の令状によることを要しない。本記述では、捜査機関が身体の拘束を受けている被疑者の顔写真を撮影している。被疑者の顔を撮影することは「裸」にするとはいえないため、218条3項により、同条1項の身体検査令状を要しない。

ウ 誤っている

222条1項本文・131条2項。131条2項は「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない」としている。その趣旨は、女性の名誉と羞恥心を保護し、かつ手続が公正に行われたことを客観的に担保することにある。そして、女子の身体の搜索の場合と異なり、急速を要する場合でも115条但書のような例外規定はない。よって、捜査機関が女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子を立ち会わせなければならない。このことは、立ち合わせる旨の条件が付されているか否かとは無関係である。

エ 正しい

222条1項本文・102条、106条。搜索差押許可状による身体の搜索の範囲は、身体そのものの外、着衣を含み、また身体は外表だけでなくその内部についても搜索し得るとするのが通説である。最決昭55.10.23（百選28事件）は、強制採尿につきカテーテルなどを用いて体内にある尿を強制的に採取する行為も、搜索差押許可状によることを認めている。もっとも、肛門等の体腔内に挿入された異物を身体検査をして採取する場合には、その身体検査の基本的な性質は搜索であるものの、その方法は検証としての身体検査と異なることがなく、慎重な配慮が必要であるから、搜索令状の他に身体検査令状が必要と解されている。かかる基準に照らせば、単に下着の中を搜索するにとどまる場合には、検証としての身体検査の性質を有しているとはいえず、別途、身体検査令状は不要といえる。なお、学説は、身体の外表面であっても通常衣服で覆われている部分を露出して調べる行為は、それが身体の部位の見分にとどまらず証拠物等の探索・発見を目的としている場合、身体検査令状に基づき実施するのが適切であるとし、身体検査令状を必要とする見解が多い。

オ 誤っている

最決昭55.10.23（百選28事件）は、強制採尿における令状の種類につき、「適切な法律上の手続について考えるのに、体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには搜索差押令状を必要とする」としている。よって、強制採尿においては、搜索差押許可状で足り、身体検査令状による必要はない。なお、判例は、「ただし、右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の搜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑訴法218条5項〔注：現6項〕が右搜索差押令状に準用されるべきであつて、令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である」としている。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢3となる。

